

1502795-14.2022.8.26.0266

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL VIEIRA PATARA

Comarca: Itanhaém

Foro: Foro de Itanhaém

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... a autoria e a materialidade do crime de tráfico. Neste sentido: 'PROVA - Testemunha - Crime de tráfico de entorpecentes - Depoimento prestado por policiais - Validade - Presunção de que, no desempenho de suas funções, agem escorreitamente. A circunstância de ser policial a testemunha não afeta (positiva ou negativamente) o valor probante de sua palavra Aprioristicamente, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itanhaém

3ª Vara

Avenida Rui Barbosa, 867, ., Centro - CEP 11740-000, Fone: (13) 3422-1215,

Itanhaém-SP - E-mail: itanhaem3@tjsp.jus.br

Processo nº:

1502795-14.2022.8.26.0266

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Repte(a)(s):

Justiça Pública

Reqdo(a)(s):

TAMIRIS DA SILVA ARRUDA

MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). RAFAEL VIEIRA PATARA.

Vistos.

TAMIRIS DA SILVA ARRUDA foi denunciada e está sendo processada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 27.07.2022, por volta das 11h00min, na Rua Santa Ana de Jesus, Jardim Sabaúna, nesta cidade e comarca de Itanhaém, a agente supra apontada trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 02 (duas) porções de cocaína, 10 (dez) porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida por maconha e 09 (nove) pedras de crack, derivado da cocaína, fazendo-o sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 11.08.2022 (pág. 81).

A ré foi citada (pág. 88) e apresentou resposta escrita à acusação (págs. 98/99).

Durante a instrução criminal foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação, seguindo-se o interrogatório da ré (págs. 137/138).

Em sede de memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva, condenando-a nos exatos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu a aplicação do redutor disposto no §4º, do artigo 33 da Lei 11.343/2006, com a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (pág. 01), pelo boletim de ocorrência (págs. 06/08), pelo auto de exibição e apreensão (págs. 10/11), pelo laudo de exame químico toxicológico (págs. 95/97), bem como pela prova oral produzida durante a fase de instrução.

A autoria também é inconteste e deve ser atribuída a acusada.

A testemunha arrolada pela acusação, Claudinei Ferreira de Souza, Policial Civil, ouvido em Juízo, disse que em patrulhamento por local conhecido como ponto de tráfico, visualizaram a ré em movimentação típica de traficância, tendo um indivíduo entregado algo para ela, a qual, por sua vez, entregou outra coisa ao indivíduo. Desse modo, decidiram, por então, abordar a ré que prontamente confirmou a traficância e tirou do bolso os entorpecentes e R\$ 34,00 (trinta e quatro reais) advindo da venda do tráfico.

A testemunha arrolada pela acusação, Reinaldo Barbosa Santos, Policial Civil, ouvido em Juízo, apresentou os mesmos fatos que seu colega de profissão.

Não há razão suficiente a invalidar os depoimentos dos Policiais, por suspeitos ou impedidos de depor, só porque ostentam essa qualidade, pois, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito.

Ademais, é pacífico na jurisprudência que:

"A alegação de que a decisão estaria baseada na palavra dos policiais responsáveis pela prisão, além de incorreta, não seria suficiente para desacreditá-la, à falta de outros elementos que ao menos indicassem qualquer interesse dos policiais em incriminar os réus. Não se pode presumir que agentes públicos, no desempenho de suas funções, tenham que adotar conduta diversa do natural apenas com o intuito de justificar as suas ações. E, pequenas divergências existentes entre as declarações prestadas pelos policiais militares não bastam, por si sós, para infirmá-las. 'O testemunho dos policiais é coerente e não há nos autos qualquer indício de que tenham agido de forma abusiva ou para consciente e injusto prejuízo do réu. A propósito, não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais. Frise-se, ademais, que pequenas contradições em seus testemunhos não têm o condão de comprometer todo o acervo probatório, haja vista que, diante do número de ocorrências por eles atendidas e, por vezes, a semelhança dos casos, faz com que, em alguns pontos, a narrativa seja diferente. O importante, todavia, é que seus depoimentos se coadunem no principal, sendo irrelevantes pequenos detalhes olvidados ou confundidos, considerando que a mente humana não é perfeita. E, no caso, os policiais foram claros ao afirmar que o réu se desfez dos invólucros contendo entorpecentes, fato, aliás, admitido por ele próprio em juízo. (Apelação Criminal n.º 993.08.031854-9 Relator Des. Pinheiro Franco 5ª Câmara. V.U. 31.07.2008)'. A jurisprudência é firme no sentido de que, aliado a outras provas, o depoimento dos policiais é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico. Neste sentido: 'PROVA - Testemunha - Crime de tráfico de entorpecentes - Depoimento prestado por policiais - Validade - Presunção de que, no desempenho de suas funções, agem escorreitamente. A circunstância de ser policial a testemunha não afeta (positiva ou negativamente) o valor probante de sua palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição. Afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau

de confiabilidade, segundo os critérios ordinariamente aplicados - Recurso parcialmente provido'. (Apelação Criminal n. 993.07.105623-5 - Sumaré - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Souza Nery 06.08.08 - V.U. - Voto n. 13111) 'PROVA - Depoimento de policial civil - Tráfico de entorpecentes - Reconhecida a capital importância da palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado - Apelo improvido'. (Apelação n. 457.560.3/4 - Santos - 4ª Câmara Criminal - Relator: Luís Soares de Mello - 09.08.05 - V.U. Voto n. 10.840) 'TÓXICO - Tráfico - Condenação baseada em depoimentos policiais - Depoimento seguro e coerente ao incriminar o acusado - Palavra destes que somada as demais provas, merece total credibilidade - Presença, ademais, de testemunhas civis - Condenação mantida - Recurso não provido. O depoimento exclusivo de policiais é de toda validade quando coerente e corroborado pelas demais provas coligidas nos autos'. (Apelação Criminal n. 181.618-3 - Tietê - 4ª Câmara Criminal - Relator: Augusto Marin - 12.06.95 - V.U.)" (TJSP, Apelação nº 3005426-36.2013.8.26.0082, 10ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. FRANCISCO GALVÃO BRUNO, j. 31.03.2016).

Os testemunhos dos Policiais são suficientes para, com as demais provas carreadas aos autos, comprovarem a ocorrência do fato típico, e embasarem um decreto condenatório à ré, vez que dotados de fé pública e idoneidade em suas alegações, mormente por terem corroborado os depoimentos na fase inquisitorial.

A ré, Tamiris Da Silva Arruda, interrogado em Juízo, confessou os fatos descritos na denúncia. Disse que estava vendo os entorpecentes há pouco tempo.

A responsabilidade penal da ré é nítida, mormente pelas provas colhidas, em especial pela prisão em flagrante e o auto de exibição e apreensão, somados aos depoimentos, bem como a confissão espontânea da acusada, tornando-se prova idônea da prática delitiva.

Necessário destacar, ainda, que o tráfico de drogas é praticado às ocultas, logo, para se prolatar decisão condenatória não há necessidade de uma sequência de provas plenas e fartas, pois tal situação não se coaduna com a realidade fática.

A decisão condenatória deve se basear em um quadro suficiente de elementos de convicção, que seja harmônico e convergente para configurar a conduta da ré, o que de fato ocorre no presente caso.

Ainda que assim não fosse, é sabido que todos os processos criminais exibem, em maior ou menor escala, algum coeficiente de incerteza, cumprindo ressaltar, porém, que é despropositado exigir, para a procedência da acusação, grau absoluto de certeza, de vez que a solução condenatória reclama, tão só, prova suficiente da autoria e da materialidade, que não se identifica com prova maciça, incontestável, reflexo sem distorções da realidade. E prova suficiente é a que, reduzindo ao mínimo desejável a margem de erro, conduz à formulação de juízo de certeza possível, ou seja, juízo revestido de confortadora probabilidade de exatidão.

Nem se diga que a existência apenas de indícios impossibilite um decreto condenatório, pois contrariaria doutrina e jurisprudência majoritárias:

"embora não leve à certeza, a jurisprudência tem admitido a condenação quando a prova indiciária for veemente ou então quando várias pequenas circunstâncias sejam, concordes até em detalhes. Um único indício pode levar à condenação, desde que veemente. Por indício veemente entende-se aquele que, dada a sua natureza, permite razoavelmente afastar todas as hipóteses favoráveis ao acusado. (...) Às vezes uma sucessão de pequenos indícios, coerentes e concatenados, igualmente podem dar a certeza exigida para a condenação. (...) Em tal hipótese não encontramos um indício que possa ser classificado como veemente, porém a sucessão e a coerência indicam a autoria com uma dose de razoabilidade bem marcante" (Da Prova no Processo Penal - José Q. T. de Camargo Aranha).

"A prova se faz não só de maneira direta, mas também por indícios e presunções, que devem ser analisados como todo e qualquer outro elemento de convicção, à luz do princípio do livre convencimento do Juiz. Os indícios, quando não contrariados por contra indícios, ou por prova direta, autorizam o juízo e culpa do acusado e sua condenação." (TACRIM-SP - AC - Rel. Marrey Neto - JTACRIM 7/105).

Como se vê, ficou clara a prática de tráfico ilícito de entorpecentes por parte da ré, inexistindo nos autos qualquer fato que venha ilidir sua responsabilidade penal. Imperiosa, pois, a condenação.

As formas de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como sua quantidade e diversidade, denotam, às claras, sua predisposição: a entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Agentes presos em flagrante quando transportavam 561 gramas de maconha - Ausência de prova direta da finalidade mercantil - Irrelevância à caracterização do delito. Não é apenas a quantidade de substância entorpecente que deve influir no julgamento, mas o conjunto de fatores expressamente previstos no artigo 37 da Lei nº 6.368/76. Até porque, segundo ponderável corrente jurisprudencial, para a configuração do delito de tráfico, na forma consumada, não é indispensável que o agente efetue a comercialização da droga. Basta que a possua, guarde ou a tenha em depósito, sobretudo em grande quantidade, circunstância denunciadora da mercancia. - Recurso conhecido e provido." (TJMG, ACr nº 263.616-5/00, 1ª Câmara Criminal, Relª Desª MÁRCIA MILANEZ, j. 07.05.2002).

Para ilustrar, aponto as lições de LUIZ FLÁVIO GOMES:

"Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Devem-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (In EL TASSE, Adel et. AL. Legislação Criminal Especial. Vl. 6. São Paulo: Editora RT, 2009, p. 197).

Inequívoco que havia a finalidade mercantil da droga. Com efeito, faz-se necessário ressaltar, inicialmente, que a demonstração da destinação comercial das drogas não está imprescindivelmente vinculada à flagrância de ato de mercancia de narcóticos.

Nesta toada, o conjunto probatório delineado nos autos é mais do que suficiente para empregar o decreto condenatório em desfavor da ré.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, observando as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, e analisando a folha de antecedentes (págs. 37/38) observo que o réu não possui maus antecedentes. Desta forma, mantenho a pena no mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, presente a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d" do Código Penal, entretanto, a pena não poderá ficar aquém do mínimo legal por força da súmula nº 231 do STJ, deste modo mantenho a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira e última fase da dosimetria da pena, vislumbro estar presente a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, pois a ré é primária e a acusação não conseguiu comprovar que a ré se dedicava a atividade criminosa, nem que integrasse qualquer organização, motivo pelo qual reduziu a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Sobre a redução acima aplicada, destaco que nesse sentido já se manifestou o Supremo Tribunal Federal:

"O afastamento da causa de diminuição de pena prevista no §4.º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 exige fundamentação idônea. A ausência de provas do envolvimento em atividades criminosas ou da participação em organização criminosa deve ser interpretada em benefício do acusado e, por conseguinte, não é suficiente para afastar a aplicação da causa de redução da pena. Incidência do princípio da presunção de inocência e da regra do in dubio pro reo" (HC 103225 – RN, 2.ª T., rel. JOAQUIM BARBOSA, 11.10.2011, v.u.).

Segundo o renomado jurista e magistrado GUILHERME DE SOUZA NUCCI, em sua obra "Leis Penais e Processuais Penais Comentadas – vol.1 –Ed. Forense – 8ª ed. – 2014 – página 348" – a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33 §4º, da Lei 11343/06: "cuida-se de norma inédita, visando a redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no artigo 33, caput, ou §1º, se primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme artigo 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda.".

Vê-se, portanto, que os quatro requisitos são cumulativos, e devem estar presentes para a concessão da benesse.

Não existem dúvidas quanto aos requisitos da "primariedade", "bons antecedentes" e "integrar organização criminosa", mas estranha é a previsão a respeito de "não se dedicar às atividades criminosas". Segundo o mesmo jurista acima citado, inclusive na mesma obra, "na norma do §4º, para que se possa aplicar a diminuição de pena, afastou-se a possibilidade de ser reincidente ou ter maus antecedentes. Portanto, não se compreende o que significa a previsão de não se dedicar às atividades criminosas. Se o sujeito é reincidente ou tem maus antecedentes pode-se supor que se dedique à atividade criminosa. No mais, sendo primário, com bons antecedentes, não há cabimento em se imaginar a dedicação a tal tipo de atividade ilícita" (grifo nosso).

No caso em tela a ré é primária, impossibilitando, desta forma, a presunção de que se dedique a atividades criminosas. Pelo contrário, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que a comprovação dos requisitos "dedicação às atividades criminosas" e "participação em organização criminosa" é ônus da acusação.

Desta forma, sendo a ré primária, e não logrando a acusação comprovar que efetivamente integrasse em organização criminosa, tão pouco se dedicasse a prática de crimes, impossível a não concessão do redutor no caso em tela.

Portanto, será concedido no mínimo legal, pois a quantidade apreendida não pode ser considerada pequena, mas também nada que leve à presunção de que a ré integrava organização criminosa ou se dedicava a atividades criminosas.

Vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por força de expressa proibição legal, e por ser a pena superior a 04 anos. Assim como, em relação à concessão do "sursis" processual.

Dito isso, deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado, único adequado e suficiente para reprovar sua conduta que afeta significativamente a ordem social, tendo em vista o incurso no artigo 2º, §1º da Lei nº 8.072/90, com a redação pela lei 11.464/07, os quais justificam a imposição do regime inicial mais severo.

Posto isto, CONDENO a ré TAMIRIS DA SILVA ARRUDA qualificada nos autos, ao cumprimento 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a iniciar o cumprimento no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Recomende-se a ré na prisão em que se encontra, não podendo recorrer em liberdade, pois ainda presentes os requisitos da custódia cautelar. Outrossim, embora tenha filhos menores de idade, a guarda destes é da avó materna, portanto, não será concedida fixação de cumprimento de pena em prisão domiciliar.

Também, após o trânsito em julgado, oficie-se a Delegacia de Polícia e ao Instituto de Criminalística, autorizando a imediata destruição dos entorpecentes nos termos previstos em lei, remetendo-se auto competente.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens eventualmente apreendidos em poder da ré em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGA (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Oportunamente, intime-se a ré para efetuar o pagamento da multa.

Condene-a, ainda, ao pagamento das custas processuais, observando-se eventual condição de beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Arbitro os honorários do defensor nomeado, se o caso, no valor máximo da tabela vigente, expeça-se o necessário.

P.I.C., arquivando-se, oportunamente.

Itanhaém, 30 de novembro de 2022.

RAFAEL VIEIRA PATARA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA